

第62問

Xは、深夜に宝石店Aに立ち入り、同店内に保管されている時価100万円相当の宝石Bを持ち去った。Xは、騒ぎが収まるまでの間は、自己で保管しておくのは危険であると考えたため、友人の甲に対し、宝石店Aから盗み出した旨を伝えた上で、これを保管するよう依頼したところ、甲はこれを快諾して、預かった。

しかし、甲は、自分の部屋に適当な保管場所がなかったため、甲の夫である乙に「盗んできちゃったものなんだけど、あなたの金庫に入れておいてくれない。」と依頼した。乙は、甲が盗んできたものであると誤信し、これを了承し、金庫に保管した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

また、甲が、第三者Yに対して、Xから預かった宝石Bを、事情を明かして100万円で売却し、その代金を費消した場合はどうか。

第1 設問前段について

1 甲の罪責

甲に盗品等保管罪（256Ⅱ）が成立することは特に問題がない。

次に、乙に対する盗品等保管罪の教唆犯（61）も成立する。また、正犯である乙に257条1項の適用が認められる場合には、257条1項の準用が認められる余地があるが、下記のように判例はこれを認めていないから、準用の余地はない。

なお、盗品等保管罪と、乙に対する盗品等保管罪の教唆犯は、追求権侵害の一個性に鑑み、包括一罪とすべきだろう。

2 乙の罪責

(1) 盗品等保管罪は、本犯者からの依頼を受けて保管した場合だけではなく、盗品等関与罪の犯人からの依頼を受けて保管した場合にも成立するから、乙にも、同罪が成立する。

(2) もっとも、甲と乙は夫婦であって、257条1項所定の親族関係がある。そこで、257条1項所定の親族関係は誰と誰との間に必要かという問題が生じる（**論点** 257条1項における親族関係は犯人と誰との間に必要か  旧H10-2）。

判例（最決昭38.11.8）は、「刑法257条1項は、本犯と赃物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであるから、……たとい赃物に関する犯人相互の間に右所定の配偶者たる関係があってもその刑を免除すべきでない」としており、盗品等関与罪の犯人同士の上に親族関係があったとしても、同条は適用されない。

(3) また、乙は、甲が盗んできたものであると誤信しているが、通説は、257条を一身の処罰阻却事由であると解し、故意や責任を阻却しないとしている（**論点** 親族関係の錯誤（257Ⅰ））。

 261 頁  132 頁

 261 頁  132 頁

第2 設問後段について

1 設問後段では、甲の行為に横領罪（252Ⅰ）が成立するかを検討することになる。

2 委託信任関係の有無が問題となるが、判例（最判昭36.10.10参照）は窃盗犯人との委託信任関係でも保護に値すると解する立場に立つとしているから、甲には横領罪が成立する（**論点** 盗品（売却代金）の横領  予H26,旧H4-2,H14-2,H20-2）。

3 なお、宝石Bを第三者Yに対して事情を明かして売却していることからすれば、詐欺罪（246Ⅰ）は成立しない。

 240 頁  112 頁

答案構成

第1 設問前段について

1 甲の罪責

盗品保管罪成立（256 I）

↓

盗品保管罪の教唆犯（61 I）の成立

↓

257条1項の準用なし

↓

両罪は包括一罪となる

2 乙の罪責

盗品保管罪成立

↓

257条1項適否

↓

257条1項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要であり、盗品等関与罪の犯人相互に同条所定の関係が存する場合には適用されない

↓

あてはめ

↓

親族関係の錯誤

↓

犯罪の成否に影響なし

↓

乙には盗品等保管罪が成立し、刑の免除等はない

第2 設問後段について

1 横領罪（252 I）

↓

2 「自己の占有する」「他人の物」

↓

窃盗犯（無権限者）との間の委託信任関係は保護に値するか

↓

肯定説

↓

「横領」

↓

横領罪成立

↓

3 詐欺罪不成立

↓

4 盗品保管罪と横領罪は併合罪（45前段）となる

第1 設問前段について

1 甲の罪責

甲は、Xが宝石店Aから盗み出した宝石Bを保管するよう依頼され、これを快諾して預かっているから、「盗品」(256条1項)を「保管」(同条2項)したものととして、盗品保管罪が成立する。

次に、乙を唆して盗品を保管させた点については、盗品等保管罪の教唆犯(61条1項)も成立する。なお、乙は宝石Bを甲が盗んできたものであると誤信しているが、下記のようにこれは有意な事情ではない。

また、正犯である乙に257条の適用が認められる場合には、同条の準用が認められる余地があるが、下記のように自説はこれを認めないから、準用の余地はない。

なお、盗品等保管罪と乙に対する盗品等保管罪の教唆犯は、追求権侵害の個性に鑑み、包括一罪とすべきである。

2 乙の罪責

(1) 乙も、甲から、「盗品」であることを知りながら、宝石Bの保管を依頼され、これを「保管」しているから、甲と同様、盗品保管罪が成立する。

(2)ア ここで、乙は甲の「配偶者」であるから、乙について刑が免除される可能性がある(257条1項)。しかし、窃盗犯人Xや被害者Aとの間にはそのような関係がない。

そこで、257条1項所定の親族関係は誰と誰との間に必要か、問題となる。

1

盗品等関与罪の犯人が親族たる本犯者を保護したり、本犯者の利益にあずかったりするために本犯の犯罪に関与することは社会類型的好くみられるところであり、また、そのような関与は期待可能性が乏しいといえる。

それゆえ、257条1項は、盗品等関与罪が被害者の追求権を侵害するのみならず、本犯者庇護という事後従犯的側面を有することを併せて考慮し、親族が本犯の場合には、適法行為の期待可能性が減少することを理由に、一身的に処罰を阻却し、刑の免除を認めたものであると考えられる。

そうだとすれば、同項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯人との間に必要であると解すべきである。

なお、盗品等関与罪の犯人相互に本条の関係が存する場合にも、責任減少を理由として本条の適用を認める見解があるが、本罪の事後従犯的性格を考慮すれば、盗品等関与行為は、本来本罪以外の領得罪を対象とするというべきであり、否定すべきである。

イ 本犯はXであり、Xと乙の間には257条1項所定の親族関係はないので、同項が適用されることはない。

(3)ア しかし、本問で乙は宝石Bについて、妻である甲が盗んできたものであると誤信している。このような親族関係の錯誤は、盗品等保管罪の成立に影響を及ぼすか。

イ 上記のように、257条1項は、盗品罪の犯人庇護(事後従犯)的側面に着目し、期待可能性が弱まることを考慮して規定された一

2

身的処罰阻却事由である。そうだとすれば、たとえ盗品等関与罪の犯人が、親族関係を誤信したとしても、故意や責任を阻却することではなく、犯罪の成否に影響することはない。

- (4) したがって、本問でも乙の上記錯誤は盗品等保管罪の成立に影響を及ぼさないから、乙には盗品等保管罪が成立し、刑の免除等はない。

第2 設問後段について

- 1 設問後段では、甲が第三者Yに事情を明かして宝石Bを売却した上で、その代金を費消している。この行為は、横領罪（252条1項）の構成要件に該当する可能性がある。

- 2(1) まず、窃盗犯人Xから委託を受けて保管している宝石Bは、宝石店Aの所有物であるから、「自己の占有する」「他人の物」に当たるのは明らかである。

- (2) また、明文にはないが横領罪の占有は所有者との委託信任関係に基づくものである必要がある。横領罪の法定刑が遺失物等横領罪（254条）よりも重い根拠は、委託信任関係を破る点にあるからである。

もっとも、本件では、委託信任関係は本権者との間ではなく、窃盗犯人Xとの間に存する。それでは、そのような無権限者との間の委託信任関係を刑法上保護すべきか。

刑法の目的は、個人の法益保護にとどまらず、財産秩序の維持にある。そうだとすれば、刑法における要保護性は民法とは別に考えるべきである。

ここで、外形上委任関係があり、これを裏切って財産を領得する行

3

為は、財産秩序維持の観点からして、刑法をもって禁圧すべきであると評価できる。この意味で、委託者に権利があるかどうかは犯罪の成否に影響しない。

また、窃盗犯人の占有も刑法上の保護に値するとして、それに対する窃取も窃盗罪を構成すると解されている以上、それとの均衡も図るべきである。

したがって、無権限者との間の委託信任関係も保護に値すると解する。

本問でも、上記Xとの間の委託信任関係も保護に値する。

- (3) そして、「横領」とは、委託の趣旨に背いて権限なく所有者でなければできないような処分をする意思、すなわち不法領得の意思を発現（実現）する行為を指すと解すべきところ、甲のYへの売却行為は、不法領得の意思の発現行為といえるので、「横領した」といえる。

- (4) なお、盗品等関与罪と横領罪は罪質が異なるため、同罪の成立は横領罪の成否に影響を及ぼさない。

よって、甲の上記行為に横領罪が成立する。

- 3 また、宝石Bを第三者Yに対して事情を明かして売却していることからすれば、詐欺罪（246条1項）は成立しない。

- 4 以上より、甲には、盗品保管罪と横領罪が成立し、後者には盗品の追求権侵害とは別に信任関係の破壊が認められる以上、両罪は別個の行為・法益侵害であるから、併合罪（45条前段）となる。

以上

4